

《【문제9.6】

<사례>

행정청 A는 甲이 운영하는 공장에 대하여 `토양환경보전법` 위반을 사유로 사용중지 명령을 내렸다. 甲은 해당 처분이 처분 권한이 없는 자에 의해 행해진 것으로서 중대하고 명백한 하자가 있어 당연무효라고 주장하며 무효확인소송을 제기하였다. 소송 계속 중 甲은 공장 가동이 중단될 경우 거래처와의 계약 위반으로 인해 회복하기 어려운 막대한 손해가 발생할 것을 우려하여, 판결 확정 시까지 처분의 효력을 멈춰달라는 가구제 수단을 강구하고 있다. 한편, 인근 주민 乙은 행정청 A가 甲에게 내린 사용중지 명령에 대하여 무효확인소송을 제기하면서, 행정청 A가 향후 해당 부지에 대하여 내릴지도 모를 다른 완화된 처분을 미리 금지해달라는 가처분을 신청하고자 한다.

(물음2) 무효확인소송에서 민사소송법상 가처분 규정이 준용될 수 있는지에 관한 판례의 입장을 기술하고, 乙이 신청하려는 예방적 금지 성격의 가처분이 허용되는지 답하라.》

<문제9.6의 물음2> 무효확인소송에서 가처분의 준용 여부와 예방적 금지 성격의 가처분 허용 여부

I 문제의 제기

- 사안에서 甲은 사용중지 명령처분에 대한 무효확인소송을 제기하면서 처분의 효력을 정지하기 위한 가구제 수단을 모색하고, 乙은 행정청 A의 장래 처분을 금지하기 위한 예방적 가처분을 신청하려는 상황이다. 쟁점으로 <무효확인소송에서 민사소송법상 가처분 규정의 준용 가능 여부와 행정청의 장래 처분을 사전에 금지하는 예방적 금지 가처분의 허용 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 무효확인소송에서 가처분 준용에 관한 판례의 입장과 예방적 금지 가처분의 인정 여부에 대해 답한다.

II 무효확인소송에서 민사소송법상 가처분 규정의 준용 여부

1. 판례의 일반적인 태도

(1) 항고소송에서의 부정

- “대법원”은 취소소송이나 무효확인소송과 같은 항고소송에서 민사소송법상의 가처분 규정이 준용될 수 없다는 입장을 확고히 하고 있다. “판례”는 “행정소송법 제23조”에서 규정하고 있는 집행정지 제도가 민사소송법상 가처분에 대한 특칙이라고 본다.

(2) 부정의 근거

- 항고소송은 행정청의 처분을 대상으로 하는 소송이므로, 사법부가 가처분을 통해 행정청의 행위를 미리 금지하거나 임시 지위를 설정하는 것은 권력분립의 원칙에 반하고 행정권의 1차적 판단권을 침해할 우려가 있다는 점을 주된 근거로 삼는다.

2. 당사자소송과의 비교

- “대법원”은 국가를 상대로 하는 당사자소송에서는 “행정소송법 제44조 제1항”이 집행정지 규정을 준용하지 않고 있다는 점을 근거로 민사소송법상의 가처분 규정이 준용될 수 있다고 판시하여 항고소송과 구분하고 있다. 그러나 사안의 乙이 제기하는 소송은 항고소송인 무효확인소송이므로 위 부정설의 법리가 적용된다.

III 예방적 금지 성격의 가처분 허용 여부

1. 예방적 금지소송과 가처분

- 예방적 금지소송이란 행정청이 특정한 처분을 하지 못하도록 미리 구하는 소송이다. 乙이 신청하려는 가처분은 본안소송으로서 예방적 금지소송이 인정됨을 전제로 그 가구제 수단으로서 기능을 한다.

2. 판례의 입장

(1) 본안소송의 부적법성

- “대법원”은 예방적 금지소송을 현행 행정소송법상 허용되지 않는 무명항고소송으로 본다. “판례”는 행정청이 장래에 내릴 처분을 미리 법원이 금지하는 것은 행정권에 대한 사법권의 지나친 간섭이라고 판단하여 이를 부적법 각하한다.

(2) 가처분의 불허

- 본안소송인 예방적 금지소송 자체가 허용되지 않으므로, 그에 부수하는 가구제 수단으로서의 예방적 금지 가처분 역시 허용될 수 없다. “판례”는 처분의 효력 발생 이후에 집행정지 등을 통해 다루는 것 외에, 장래의 처분을 미리 막는 가처분 형식의 권리구제는 인정하지 않는다.

IV 사안의 적용

1. 乙의 무효확인소송과 가처분 신청

- 乙은 사용중지 명령에 대하여 무효확인소송을 제기하면서 가처분을 신청하였다. 그러나 앞서 살펴본 “판례”의 태도에 따르면 무효확인소송과 같은 항고소송에서는 민사소송법상의 가처분 규정이 준용되지 않는다.

2. 예방적 금지 가처분의 적법성 검토

- 乙이 구하는 향후 내릴지도 모를 완화된 처분을 미리 금지해달라는 신청은 전형적인 예방적 금지 성격의 가처분이다. 우리 “판례”는 예방적 금지소송 자체를 부정할 뿐만 아니라 항고소송에서의 가처분 준용도 부정하고 있으므로, 乙의 가처분 신청은 법적 근거가 없어 부적법 각하될 것이다. 乙은 실제 처분이 내려진 이후에 그 처분에 대하여 다시 무효확인소송이나 취소소송을 제기하고 집행정지를 신청하는 방식으로 대응해야 한다.

V 결론

- 무효확인소송에서 민사소송법상의 가처분 규정이 준용될 수 있는지에 대하여 “대법원”은 “행정소송법 제23조”의 집행정지 규정이 특칙으로서 존재한다는 점과 권력분립 원칙을 근거로 이를 명백히 부정하고 있다. 특히 乙이 신청하고자 하는 예방적 금지 성격의 가처분은 본안소송인 예방적 금지소송의 허용 여부와 직결되는데, “판례”는 법문에 명시되지 않은 무명항고소송과 그에 따른 가처분을 일체 인정하지 않는다. 따라서 乙의 가처분 신청은 허용되지 않는다. 이러한 법리는 사법부가 행정청의 처분 권한을 사전에 제약하는 것을 극도로 경계하는 태도를 보여주며, 국민의 가구제 수단이 사후적 수단인 집행정지에 한정되어 있다는 현행 행정쟁송법 체계의 한계를 나타낸다.